

2014년 상표법 2차 시험 기출 해설

-정진길 변리사-

총 평

1. 다논점의 사례문제와 단문형 문제가 모두 출제됨
2. 기본서 등을 통한 기본이론정리(A-2, B-1, B-2) 및 암기
3. 상표법의 법리 이해(A-1, B-1)
4. 평상시 접해보지 못한 문제에 대해서 침착함을 가지고 머릿속의 지식을 논리정연하고 깔끔한 목차로 현출시키는 것이 중요하였을 것으로 생각됨

[문제-1 해설]

I. 문제의 소재

§2③(서비스표)

상표, 서비스표간에 소극적 효력 미침

II. 설문(1)의 해결 [10점]

1. 2002년 최초출원시 거절이유 - §6①3

(1) 의의 및 취지

(2) 사안판단 - 커피전문점경영업 등의 성질표시 해당 O

2. 2014년 출원시 2002년 출원의 거절이유 극복가부 - §6②

(1) §6②의 의의 및 취지

(2) 사용에 의한 식별력 획득 여부 - 전국 / 2008년 또는 2009년 식별력 획득

(3) 출원인 주장, 입증하면 극복 可

3. 2014년 출원시 예상되는 새로운 거절이유 - §7①7

(1) 의의 및 취지

(2) 동종성 - 커피 v. 커피전문점경영업 등 - 동종성 인정

(3) 표장의 유사여부 - 비유사 (Coffee bean 요부 X)

(4) 적용 X

III. 설문(2)의 해결 [8점]

1. 6조 적용 X(cantabile 결합),

7조1항4호 적용 X(모방상표 아니거나, 07년 개정법 취지)

2. 7조1항7호 - X

상표 비유사 - 유사판단시점 출원시(2007.12월) 기준 Coffee bean 식별력 획득 하지 않았으므로 요부 아님

3. 인식도 판단 - 7조1항9호 및 10호 적용 X(출원시-2007.12월 주지·저명하지 않음)

4. 7조1항11호 - O

(1) 출처혼동방지규정(判)

(2) 09년 12월말 전에 인용상표 특출인 & Coffee bean(判)

5. 7조1항12호 - O

(1) 속지주의 예외

(2) 국외(특히, 미국) 특정인의 출처로 인식되었을 것을 전제함

(3) 부정한 목적 - 상표유사성, 미국 유학사실, 상품 동종성

6. 이해관계, 제척기간, 인용심결(소급소멸)

IV. 설문(3)의 해결 [12점]

1. 甲의 상표권 행사가부

(1) 침해의 의의 및 성립요건

일응 유효 O/상표적 사용 O/선사용권 적용 X - 출원시(07.12월) 특출인 X

(2) 보호범위 내인지 여부 - X

1) 동종성 존재

2) 표장 비유사 - coffee bean을 요부로 볼 수 없음

(3) 51조1항2호 효력제한 - O

(4) 권리남용 - 혼동목적의 출원 적용 가능성 有/무효사유명백

(5) 상표권 행사 不可

2. 甲사용행위가 乙권리 금지권 범위 내인지 여부

(1) 甲의 사용은 상표적 사용 O

(2) 보호범위 내인지 여부

1) 동종성 - 커피전문점경영업 v. 커피원두, 커피(甲사용상품) - O

2) 표장 유사 - coffee bean 요부로 볼 수 있음

(3) 51조1항2호 - X

§6②관련 (判)

(4) 금지권 범위 내 O

평: [문제-1]

문제-1은 작년부터 중요한 판례로 소개되어왔던 문제로서 낯설지는 않았을 것으로 생각되나, 사실관계(시간적 선후관계, 등록된 상표, 사용상품)를 꼼꼼히 파악하였는지, 상표법의 법리에 대한 이해를 기초로 타당한 결론을 도출해냈는지 여부에서 득점이 나눌 것으로 예상된다.

[문제-2 해설]

I. 문제의 소재

의정서상 국제출원의 의의

II. 설문(1)의 해결 [7점]

1. 본국관청의 역할과 절차수행

(1) 의미

본국관청에 국제출원서가 접수된 후, 방식심사 및 합치여부심사를 마친 후, 국제사무국에 국제출원서 송부할 때까지의 절차 & 국제사무국이 국제출원서 접수한 후 방식심사 결과 하자발견하여 본국관청 및 출원인에게 통지하고 그에 따라 하자 보정하는 절차

(2) 기초출원의 존재 및 동일성¹⁾ 확인

(3) 출원인 적격의 확인

(4) 언어

2. 국제사무국의 역할과 절차수행

(1) 방식심사 - 의정서 양식에 맞는 출원인지

(2) 국제등록부상의 등록²⁾

(3) 지정국 관청에 통보, 국제등록부 공고

(4) 수수료

III. 설문(2)의 해결 [6점]

1. 시기적 측면의 적절성 (의정서 5(2)(b))³⁾

영역확장통지일(2012.11.1.)로부터 18개월 내인 2013.12.1.(1년 1개월 경과시점) 가거절이 유통지 하였으므로 적절함

2. 내용적 측면의 적절성 - §7①7

(1) 의의 및 취지

(2) 타인의 선등록상표 O / 상표 유사 O

(3) 상품유사여부

운동화 동종상품 v. 운동화 - 유사 / 운동화 동종상품 v. 티셔츠 - 비유사

(4) 출원일체의 원칙 - 전체 거절 - 적절함

(5) 보론 - 삭제보정 또는 국제등록부상의 감축 등으로 회피가능

-
- 1) 의정서 3(1); 본국관청은 인증시점에 당해 출원서의 기재사항이 기초출원 또는 기초등록의 기재사항과 일치함을 증명하여야 하며, 추가로 다음 사항을 표시하여야 한다. (i) 기초출원의 경우 그 출원일 및 출원번호 (ii) 기초등록의 경우 그 등록일, 등록번호 및 당해 기초등록이 기초하는 출원의 출원일, 출원번호 또한 본국관청은 국제출원일도 표시하여야 한다.
- 2) 의정서 3(4); 국제사무국은 제2조의 규정에 의하여 출원된 표장을 즉시 등록하여야 한다. (중략) 국제사무국은 지체없이 그러한 국제등록을 관련 관청에 통보하여야 한다. 국제사무국은 국제출원에 기재된 사항을 기초로 하여 국제등록부에 등록된 표장을 정기공보에 게재하여 공고하여야 한다.
- 3) 계약당사자는 제(a)호의 규정에 불구하고 본 의정서에 의한 국제등록에 대하여 제(a)호에서 언급한 1년의 기한을 18월로 대체함을 선언할 수 있다.

IV. 설문(3)의 해결 [7점]

1. 일본 기초출원의 거절결정 확정이 국제등록에 미치는 효과
 - (1) 종속성의 의의 및 내용
 - (2) 사안의 경우
 - 1) 국제등록일의 확정 2012.10.1.
 - 2) 국제등록일부터 5년 이내인 2014.1월이므로 국제등록 소멸
2. 일반 상표출원으로 전환시 요건 및 효과
 - (1) 전환(§86의39)의 요건
시기적 요건 3개월 / 상표 동일 / 상품 (일반상표출원 C 소멸된 국제출원)
 - (2) 전환제도 이용시 효과
 - 1) 출원일 소급 - 소멸된 국제출원의 국제등록일(2012.10.1.)
 - 2) 심사의 특례규정 적용 없음 (등록된 사정 없음)

평: [문제-2]

설문(1)에 있어서 본국관청 역할 및 절차수행은 사례집 및 GS의 단문을 통하여 많이 접해 본 문제였던 반면, 의외의 부분이었던 국제사무국의 역할은 기본서를 정독하시면서 해당부분을 스치듯 몇 번이라도 보신 분들이 유리하였을 것으로 생각됨.

설문(2)에 있어서 ‘가거절이유통지’라는 용어를 몰랐을지라도, ‘의견제출통지’로 해석하여 푸셨을 것으로 예상되며, 내용적 측면과 관련하여, 상품의 유사를 상품별로 구체적으로 판단하는 것에서 득점이 나눌 것으로 예상됨.

설문(3)은 국제등록의 종속성과 관련된 전형적인 문제였음.

[문제-3 해설]

I. 문제의 소재

지리적표시의 보호
§2③, §2④(지표증)

II. 설문(1)의 해결 [10점]

1. 지리적표시 단체표장 제도

- (1) 의의 및 취지(§2①3의4)
- (2) 출원인 적격(§3의2 괄호)

2. 지리적표시 증명표장 제도

- (1) 의의 및 취지(§2①4의2)
- (2) 출원인 적격(§3의3)

3. 사안의 경우

- (1) 지리적표시 정의(§2①3의2) 합치여부 - O (고품질 원유 바탕)
- (2) 출원인 적격 만족여부 - O

甲은 치즈의 등급(품질)에 대한 인증업무를 업으로서 수행하는 자이며, 본인 스스로 치즈를 제조하지 않고, 동일·유사상표를 상표출원 하는 등의 사정이 존재하지 않으므로 출원인 적격 만족함

- (3) 甲은 치즈를 생산, 제조 또는 가공하는 자가 아니므로 지표단 출원 不可
+ 단체라는 사실 없으므로, 개인인 경우 단체표장출원 不可

III. 설문(2)의 해결 [10점]

1. 지리적표시 증명표장권 침해의 성립요건

유효한 권리 O / 정당권원 無

2. 지리적 출처표지로서의 사용 - Meaux 가 그대로 포함되어 있음

3. 보호범위 내인지 여부

- (1) 상품 동일 (치즈)
- (2) 상표
 - 1) 제1사용표장 유사 - Meaux 부분이 요부
 - 2) 제2사용표장 비유사

4. 효력제한 사유 (§51②)

산지, 현지명 아님

乙은 Meaux 지역업자 아님,

5. 제1사용표장 - 승소

제2사용표장 - 패소

-> 둘 모두에 대하여 소제기시 일부승소

IV. 설문(3)의 해결 [10점]

- 1. 6조1항3호, 4호 - X

2. 7조1항1호의5 - X

동맹국 또는 그 공공기관의 증명용 인장 X

3. 7조1항7호의2

(1) 의의 및 취지 / 제2사용표장 - 적용 X

(2) 제1사용표장 - 적용 O

타인의 선등록 지표증 / 상표 유사 - Brie de Meaux 요부 / 상품 동일

4. 7조1항9호의2 - X

국내에서 알려진 바 없음

5. 7조1항12호의2 - O

(1) 의의 및 취지 / 속지주의 예외

(2) 유럽에 인식된 타지역의 지리적 표시 / 유사 / 부정한 목적 (한-EU FTA 통과 후)

6. 7조1항17호

(1) 의의 및 취지 / 제2사용표장 - 적용 X

(2) 제1사용표장 - 적용 O

7. 제1사용표장, 제2사용표장 모두 등록 不可

평: [문제-3]

설문(1)은 지리적표시 증명표장출원이 지리적표시 단체표장출원보다 바람직하다는 근거만을 서술하기에는 배점이 크기 때문에, 지리적표시 증명표장과 지리적표시 단체표장의 제도의 의의와 같은 일반론을 어느 정도 서술할 필요가 있어 보이며, 대충 얼버무려서 증명표장출원이 타당하다고 포섭하는 것이 아니라, 구체적으로 사안포섭하여 지리적표시 증명표장출원이 바람직하다는 결론을 내려야만 좋은 점수 예상됨.

설문(2)의 경우 2가지 사용표장에 대하여 모두 판단해야 하며, 지리적 출처표지로서 사용인지 여부, 표장의 유사여부 판단이 핵심.

설문(3)은 관련 논점을 모두 추출하여 논점을 놓치지 않는 것과, 적용여부를 표장별로 꼼꼼히 판단하였는지 여부에서 득점이 나눌 것으로 예상됨.

I. 문제의 소재

소리상표 제도의 도입 및 취지(§2①1다)

II. 설문(1)의 해결 [7점]

1. 거절이유 제1점의 적용 법규정

- (1) 10조 - 소리파일과 상표건본 함께 제출
- (2) 23조1항4호(정의규정 위반)
 - 1) 소리파일과 상표건본 함께 제출
 - 2) 시각적 표현이 사실적으로 기재되지 않은 경우
 - 3) 시각적 표현과 소리파일이 일치하지 않는 경우

2. 출원시 유의점

- (1) 출원서에 그 취지, 설명 및 시각적 표현을 기재(§9③) - 시각적 표현 미기재시 출원일 불인정 사유(§9의2①3의2)
- (2) 시각적 방법으로 사실적으로 표현 - 시각적 표현만을 보고 소리를 인식하거나 동일하게 재현할 수 있는지 여부 고려
- (3) 사실적 표현과 일치하는 소리파일 제출하여야 함 / 악보제출할 수 있음 / 상표건본 제출하지 않음

III. 설문(2)의 해결 [7점]

1. 기능성 이론의 의의 및 취지(§7①13)

2. 기능성 있는 소리상표의 유형 - 심사기준

- i) 상품의 특성으로부터 작용하는 특정 소리 ii) 상품의 사용에 불가결하거나 일반적으로 사용되는 소리 iii) 상품의 판매증가와 밀접한 원인이 되는 소리는 기능성이 있는 것으로 보아 등록을 불허한다.

3. 의견서 작성의 요지

“뚝- 뚜리두둥”과 흡사한 소리는 컴퓨터에 내장되는 마이크로칩의 특성과 무관하고, 마이크로칩을 사용함에 있어서 불가결하거나 일반적으로 사용되는 소리도 아니며, 당해 소리로 인해 마이크로칩의 판매가 증가된다고 볼 수도 없으므로 출원상표는 기능성이 존재하지 않는다.

IV. 설문(3)의 해결 [6점]

1. 상표적 사용 O

2. 보호범위 내인지 여부

- (1) 상품 동일 - 마이크로칩
- (2) 상표유사여부

- 1) 심사기준은 소리상표 상호간에만 유사여부 판단하나, 이는 특허청의 심사실무일 뿐이며, 심판 또는 소송단계에서는 소리상표와 타유형간의 유사여부도 문제될 수 있음

2) 유사함

3. 효력제한사유 해당여부 (§51①2, 4)

지정상품 마이크로칩의 일반적 소리 아니며, 기능을 확보하는데 불가결한 소리도 아니므로

로 효력제한 사유 적용 X
4. 권리범위에 속함 O

평: [문제-4]

설문(1), 설문(2)는 소리상표의 등록요건 및 절차에 관한 법규정 및 심사기준을 꼼꼼히 언급하였는지, 사안포섭을 구체적으로 하였는지 여부에서 득점이 나눌 것으로 예상됨.

설문(3)은 상표의 침해와 관련된 논점(유.상.보.정.제)을 검토하면 되는 문제였으며, 소리상표와 문자상표간에 유사판단에서 득점이 나눌 것으로 예상됨.